# Prüfung Assessmentjahr – Sommer 2025

## Teil Prof. Schindler

**Name:** | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

**2,170**

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Benjamin Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. Stefan G. Schmid

**Bemerkungen:**

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 12 Seiten** (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

| | |
|---|---|
| 1. Aufgabe | 24 Punkte |
| 2. Aufgabe | 24 Punkte |
| 3. Aufgabe | 26 Punkte |
| 4. Aufgabe | 16 Punkte |
| **Total** | **90 Punkte** |

**Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt. Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!**

# Aufgabe 1 — 24 Punkte

Für lange Zeit war die Forschung am Menschen nur in Teilen durch das Bundesrecht geregelt. Aufgrund der lückenhaften und unübersichtlichen Regelungen wurde der Bundesrat in einer Motion der ständerätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beauftragt, eine Verfassungsbestimmung zur Forschung am Menschen vorzubereiten. Nach intensiven parlamentarischen Beratungen wurde die neue Verfassungsbestimmung am 29. September 2009 in der Schlussabstimmung der eidgenössischen Räte angenommen und anschliessend im Rahmen eines obligatorischen Referendums am 7. März 2010 mit einer Zustimmung von 77% des Volkes und aller Kantone angenommen. Der neue Art. 118*b* BV trat am gleichen Tag in Kraft.

**Frage 1**: [10 Punkte]

Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen. Legen Sie anschliessend die spezifische Kompetenzverteilung im Bereich der Humanforschung (Art. 118*b* Abs. 1 BV) dar und kategorisieren Sie die einschlägige Kompetenz nach Umfang, Wirkung und Staatsfunktion.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen (**1 Bonuspunkt**).

Art. 118*b* Abs. 1 BV begründet eine Verbandskompetenz des Bundes (**1 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut [Der Bunde erlässt…] (**1 Punkt**) und die Stellung der Norm innerhalb der Bundesverfassung [3. Titel: Bund Kantone und Gemeinden] (**1 Punkt**). Es handelt sich dabei um eine umfassende Gesetzgebungskompetenz (**1 Punkt**) mit nachträglich derogatorischer Wirkung (**1 Punkt**), da es dem Sinn der Norm widersprechen würde, wenn die Regelungen der Kantone wegfallen bevor der Bund seine Kompetenz ausgeübt hat (**1 Punkt**). Art. 118*b* BV äussert sich nicht explizit zur Staatsfunktion, weshalb der Normalfall nach Art. 46 BV zum Zuge kommt (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader, § 6, Rz. 4 ff., 18 ff.; Fragenkatalog 3, Fragen 10, 13 und 14)*

*Fortsetzung des Sachverhalts:*

Gestützt auf die neue Verfassungsbestimmung hat der Bund das Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG) vom 30. September 2011 erlassen. Im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten herrschte jedoch Uneinigkeit darüber, wie weit der sachliche Geltungsbereich von Art. 118*b* Abs. 1 BV reicht. Eine Seite argumentierte, Art. 118*b* BV umfasse sämtliche Forschung am und über den Menschen und damit auch geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung, die sich beispielsweise auf der Grundlage von anonymisierten Daten mit dem Ernährungsverhalten von Jugendlichen aus verschiedenen Kulturkreisen beschäftigt. Die Gegenseite argumentierte, dass die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung mit anonymisierten Daten nicht von Art. 118*b* Abs. 1 BV erfasst sei, da die physische und die psychische Integrität oder die Würde des Menschen mit dieser Forschungsmethode kaum verletzt werden könne. Die Bundeskompetenz sei deshalb nur auf Forschung mit konkretem Gefährdungspotenzial beschränkt.

**Frage 2**: [14 Punkte]

Wie weit geht der Anwendungsbereich von Art. 118*b* Abs. 1 BV? Legen sie zur Beantwortung dieser Frage Art. 118*b* Abs. 1 BV aus. Stützen Sie sich im Rahmen Ihrer Auslegung auch auf den unten abgedruckten Auszug aus der Botschaft des Bundesrates zu Art. 118*b* BV. Welches Auslegungsresultat überzeugt Sie?

**Botschaft des Bundesrates zum Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen vom 12. September 2007, BBl 2007 6721.**

«Der Bundesgesetzgeber darf dann – und nur dann – regulierend in die Forschung eingreifen, wenn eine Gefährdung von Würde oder Persönlichkeit dies notwendig macht. Ein solcher *dynamischer* Ansatz vermeidet eine Überregulierung. Bevor der Gesetzgeber aktiv werden kann, bedarf es einer Einschätzung der Gefährdungssituation. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf entsteht dann, wenn ein Gefährdungspotenzial für Würde oder Persönlichkeit vorliegt; er muss verneint werden, falls dieses als vernachlässigbar eingeschätzt wird.»

Bei der grammatikalischen Auslegung wird auf den Wortlaut abgestellt (**1 Punkt**). Art. 118*b* Abs. 1 BV sagt explizit, dass die Kompetenz nur soweit geht, als dass es der Schutz der Würde und Persönlichkeit erfordert (**1 Punkt**). Dies spricht für ein enges Verständnis der Norm (**1 Punkt**).

Die teleologische Auslegung fragt nach dem mit der Norm verfolgten Normzweck (**1 Punkt**). Art. 118*b* Abs. 1 BV verfolgt den Zweck, die Würde und Persönlichkeit zu schützen, wenn der Mensch zum Objekt der Forschung gemacht wird (**1 Punkt**). Der Geltungsbereich kann daher nur soweit gehen, als dass diese Rechtgüter gefährdet sind, was ebenfalls für ein enges Normverständnis spricht (**1 Punkt**).

Die historische Auslegung fragt nach der Entstehungsgeschichte einer Norm, wie sie in den Materialien zum Ausdruck kommt (**1 Punkt**). In der Botschaft des Bundesrates

kommt zum Ausdruck, dass Überregulierung vermieden werden soll und die Kompetenz sich nur auf Bereiche mit Gefährdungspotenzial für die Würde und die Persönlichkeit erstreckt (**1 Punkt**). Dies spricht dafür, dass die Kompetenz sich nicht auf Forschungsvorhaben mit vernachlässigbarem Gefährdungspotenzial, wie in den Geistes- und Sozialwissenschaften, erstreckt (**1 Punkt**).

Die systematische Auslegung betrachtet die Stellung der Norm innerhalb der Verfassung und der Rechtsordnung überhaupt (**1 Punkt**). Art. 118*b* Abs. 2 BV stellt Grundsätze über die Forschung mit Personen auf, die sich jedoch nur auf die Biologie und die Medizin beschränken (**1 Punkt**). Dies spricht gegen ein weites Normverständnis, das auch geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung ohne Gefährdungspotenzial umfasst (**1 Punkt**).

Das Bundesgericht wendet die Auslegungsmethoden im Rahmen des pragmatischen Methodenpluralismus in der Kombination an, die am besten auf den Einzelfall zugeschnitten ist, und lehnt eine Priorisierung der Methoden ab (**1 Punkt**). Im vorliegenden Fall sprechen alle Auslegungsmethoden dafür, dass nur Forschungsprojekte, die den Menschen in seiner Würde und Persönlichkeit gefährden, von Art. 118*b* Abs. 1 BV erfasst werden, und sich die Bundeskompetenz daher auf die Forschung mit konkretem Gefährdungspotenzial beschränkt, wozu die Geistes- und Sozialwissenschaften typischerweise nicht zählen (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader, § 2, Rz. 43 ff.; Fragenkatalog 1, Fragen 7, 9 und 10)*

## Aufgabe 2 — 24 Punkte

Am 29. November 2009 wurde die eidgenössische Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» von Volk und Ständen angenommen. Dadurch fand Art. 72 Abs. 3 BV Eingang in die Bundesverfassung, der den Bau von Minaretten (schmaler Turm bei oder an einer Moschee, von dem aus fünf Mal am Tag zum Gebet gerufen wird) in der Schweiz verbietet. Die Gegner des Minarettverbots stören sich unter anderem am offenen Widerspruch, der zwischen Art. 72 Abs. 3 BV und der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV) sowie der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) entstanden ist.

**Frage 1**: [4 Punkte]

Weshalb kommt es innerhalb der Bundesverfassung zu Widersprüchen? Wie versuchen die Bundesbehörden solche Widersprüche zu bereinigen? Sehen Sie darin Gefahren?

Die Bevölkerung in der Schweiz kann die Verfassung über die Volksinitiative jederzeit ändern. Dieses direktdemokratische Mitwirkungsinstrument kann dazu führen, dass aus einem aktuellen Anlass eine einzelne Bestimmung in die Verfassung eingefügt wird, die anderen Verfassungsnormen widerspricht (**1 Punkt**). Im Rahmen der systematischen Auslegung ist deshalb darauf zu achten, dass die Verfassungsbestimmungen in praktische Konkordanz gebracht werden (**1 Punkt**) und Widersprüche innerhalb der Verfassung geglättet werden, indem sie *harmonisiert* werden (**1 Punkt**). Es besteht hier aber die Gefahr, dass bewusst in Kauf genommene Konflikte entgegen dem Normsinn «wegharmonisiert» werden und eine wertende Normenhierarchie geschaffen wird (**1 Punkt**).

*(Vgl. Fragenkatalog 1, Frage 6)*

*Der Sachverhalts ist frei erfunden!*

Der muslimische Verein X plant, am Stadtrand von St. Gallen eine neue Moschee zu bauen, die auch über ein kleines Minarett verfügt. Der Verein ist der Auffassung, das Minarettverbot stehe nicht nur in einem Widerspruch mit ihren verfassungsmässigen Grundrechten, sondern auch mit der Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK) und dem Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK) der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da ihr Bauvorhaben mit Verweis auf Art. 72 Abs. 3 BV nicht bewilligt wurde, gelangen sie mit ihrem Anliegen vor das zuständige Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen.

**Frage 2:** [8 Punkte]

Kann sich der Verein X vor dem Verwaltungsgericht St. Gallen auf die Garantien der EMRK berufen und eine Verletzung dieser Normen geltend machen? Gehen Sie zur Beantwortung dieser Frage zuerst auf die verschiedenen Systeme betreffend innerstaatliche Geltung von Völkerrecht ein und beschreiben sie, welchem System die Schweiz folgt. Gehen Sie anschliessend auf die innerstaatliche Anwendbarkeit von Art. 9 und 14 EMRK ein.

In Bezug auf die innerstaatliche Geltung von Völkerrecht wird zwischen zwei Systemen unterschieden. Das dualistische System fordert, dass Völkerrecht zuerst durch einen nationalen Rechtsakt in nationales Recht überführt wird (**1 Punkt**). Das monistische System betrachtet Völker- und Landesrecht als Einheit, weshalb Völkerrecht unmittelbar innerstaatliche Wirkung entfaltet (**1 Punkt**). Die Schweiz ist dem Monismus verpflichtet (**1 Punkt**). Somit hat die EMRK automatisch Geltung im schweizerischen Landesrecht (**1 Punkt**).

Auch im monistischen System kann nicht jede völkerrechtliche Norm im Einzelfall unmittelbar angerufen werden. Die Norm muss zusätzlich justiziabel (*self-executing*) sein (**1 Punkt**). Davon ist auszugehen, wenn diese Privaten individuelle Rechte und Pflichten vermitteln (**1 Punkt**) und genügend bestimmt sind für die direkte Anwendung durch Verwaltung und Justiz (**1 Punkt**). Art. 9 und 14 EMRK gewähren dem Individuum einen Rechtsanspruch und sind genügend bestimmt, weshalb sich der Verein X auch vor dem innerstaatlichen Verwaltungsgericht darauf berufen kann (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader § 3, Rz. 55 ff.; Fragenkatalog 2, Fragen 7 und 10)*

**Frage 3**: [12 Punkte]

Gehen Sie davon aus, dass das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen in der Nichtbewilligung des Baus einer Moschee mit einem Minarett eine Verletzung von Art. 9 und 14 EMRK erkennt, die aufgrund des klaren Wortlautes von Art. 72 Abs. 3 BV nicht durch eine völkerrechtskonforme Auslegung der Bundesverfassung bereinigt werden kann. Wie kann das Gericht mit diesem Konflikt zwischen der EMRK und der Bundesverfassung umgehen? Wäre Ihre Antwort anders, wenn das Minarettverbot nicht in der Bundesverfassung, sondern in einem Bundesgesetz verankert wäre?

*Hinweis: Allfällige kompetenzrechtliche Probleme müssen Sie nicht thematisieren.*

Das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsrecht und einfachem Völkerrecht ist nicht abschliessend geklärt (**1 Punkt**). Die Verfassung gibt folgende Anhaltspunkte:

- In Art. 5 Abs. 4 BV (**1 Punkt**) erblickt ein grosser Teil der Lehre einen grundsätzlichen Vorrang des Völkerrechts vor dem Landesrecht (**1 Punkt**).
- Art. 190 BV (**1 Punkt**) ist zwar keine abschliessende Kollisionsregel zwischen einfachem Völkerrecht und der Bundesverfassung (**1 Punkt**), spricht aber ebenfalls dafür, dass im Konfliktfall das Völkerrecht und nicht das Bundesverfassungsrecht massgeblich ist (**1 Punkt**).

Somit hätte das Gericht die Möglichkeit, das Bauvorhaben entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 72 Abs. 3 BV zu bewilligen (**1 Punkt**).

Für den Fall, dass das Minarettverbot in einem Bundesgesetz verankert wäre, lässt sich aus Art. 190 BV nichts ableiten, da dieser das Völkerrecht und Bundesgesetze für massgeblich erklärt (**1 Punkt**). Zum Verhältnis von Bundesgesetzen gegenüber Völkerrecht gibt es zwei Rechtsprechungslinien des Bundesgericht:

- Nach der sog. «Schubert-Praxis» geht eine bundesgesetzliche Norm im Konfliktfall vor, wenn der Gesetzgeber einen allfälligen Konflikt mit dem Völkerrecht bewusst

in Kauf genommen hat (**1.5 Punkt**).

- Nach der sog. «PKK-Praxis» geht Völkerrecht dem Landesrecht prinzipiell vor, insbesondere dann, wenn die völkerrechtliche Norm dem Schutz der Menschenrechte dient (**1.5 Punkt**).

Da die infragestehenden völkerrechtlichen Normen dem Schutz der Menschenrechte dienen, ist davon auszugehen, dass die «PKK-Praxis» zur Anwendung gelangt, womit der Bau ebenfalls bewilligt werden könnte (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader § 3, Rz. 60 ff.; Fragenkatalog 2, Fragen 4 und 7)*

## Aufgabe 3 — 26 Punkte

Basel war ab dem frühen 16. Jahrhundert bis 1798 einer von dreizehn sogenannten «Orten» innerhalb der Alten Eidgenossenschaft. Diese «Orte» waren weitgehend selbständig, koordinierten ihre Politik aber im Rahmen der Tagsatzung. Die Tagsatzung konnte einstimmig Beschlüsse fassen. Die Gesandten der «Orte» stimmten gemäss der Vorgabe (Instruktion) ihrer jeweiligen Regierungen.

Das Territorium Basels bestand aus der befestigten Stadt am Rhein und den ländlichen Untertanengebieten, die durch Verträge und Eroberungen unter die Kontrolle Basels gelangt waren. Während die Stadtbürger wirtschaftliche und politische Privilegien genossen, hatte die Landbevölkerung kein Mitspracherecht und unterlag der Verwaltung und Gerichtsbarkeit der Stadt.

Religiös differenzierte sich Basel von den umliegenden Orten und vom Ausland durch den reformierten Glauben. Wirtschaftlich war Basel ein Handelszentrum mit engen Verbindungen zu Frankreich und dem heutigen Süddeutschland. Im Kriegsfall konnte Basel Truppen ausheben – die Stadt besass eine Miliz bestehend aus Bürgern, die in Zünften organisiert waren, sowie aus Landbewohnern, die im Kriegsfall zur Verteidigung verpflichtet werden konnten. Im Vergleich zu den grossen Nachbarstaaten war die Streitmacht jedoch klein und auf Verteidigung ausgerichtet, was zu aussenpolitischen Abhängigkeiten führte.

**Frage 1:** [16 Punkte]

Welche Elemente definieren einen Staat? Erfüllt Basel in der Zeit zwischen dem frühen 16. Jahrhundert und 1798 diese Kriterien aus heutiger Sicht?

Nach der Dreielementenlehre von GEORG JELLINEK (**1 Punkt**) benötigt ein Staat kumulativ ein Staatsgebiet (**1 Punkt**), ein Staatsvolk (**1 Punkt**) und eine Staatsgewalt (**1 Punkte**).

Das Staatsgebiet ist ein räumlich abgegrenztes Territorium, über das der Staat seine Herrschaft ausübt **(1 Punkt).** Basel bestand aus einem fest definierten Gebiet, welches die Stadt und die ländlichen Untertanengebiete umfasst (**1 Punkt**). Das zeigt sich auch in der Akzeptanz durch das Ausland, was jedoch nur deklaratorischen Wert hat (**1 Zusatzpunkt**). Das Staatsgebiet ist damit gegeben (**1 Punkt**).

Das Staatsvolk ist eine Gruppe von Menschen, die auf dem Staatsgebiet lebt, gemeinsam vom Staat beherrscht wird oder durch ein anderes rechtliches oder politisches Kriterium verbunden ist (**1 Punkt**). Im Fall von Basel ist das Staatvolk beispielsweise als kulturell-religiöse Einheit durch den reformierten Glauben verbunden (**1 Punkt**). Die strikte rechtliche Hierarchie zwischen Stadt- und Landbevölkerung spricht jedoch gegen ein einheitliches Staatsvolk (**1 Zusatzpunkt bei Abwägung**). Das Staatsvolk ist damit erfüllt/nicht erfüllt (**1 Punkt).**

Staatsgewalt bezeichnet die Herrschaft, die der Staat ausübt (**1 Punkt**). Je nach

Staatsverständnis bedeutet dies Selbstherrschaft oder Souveränität. Selbstherrschaft (FLEINER/JELLINEK) bedeutet, dass dem Staat nicht weiter abgeleitete, ursprüngliche Herrschaftsgewalt zukommt (**1 Punkt**). Da sich die Macht von Basel nicht von der Alten Eidgenossenschaft ableitet, ist dies gegeben (**1 Punkt**). Souveränität bedeutet, dass dem Staat uneingeschränkte Letztentscheidungsmacht gegen innen und aussen zukommt (**1 Punkt**). Da Basel innerstaatlich die Letztentscheidungsmacht hatte und auch gegen aussen als mit anderen Staaten in Beziehung trat und über eine eigene Armee verfügte, ist die Souveränität gegeben (**1 Punkt**).

*Hinweis: Jeweils abweichende sinnvolle Begründungen werden ebenfalls bepunktet.*

***Max. 2 Bonuspunkte** für sinnvolle Ausführungen (Definition und Argumentation) betreffend legitime/legale Herrschaft als zusätzliche Kriterien der Staatsgewalt.*

Da Basel zu dieser Zeit über alle drei Elemente der Dreielementelehre verfügte, ist Basel als Staat zu betrachten (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader, § 1, Rz. 10ff.; Fragenkatalog 1, Frage 1 und 4)*

**Frage 2**: [10 Punkte]

1798 besetzten französische Truppen Basel, womit die Alte Eidgenossenschaft abrupt endete und Basel in die Helvetische Republik integriert wurde. Im Gefolge der Verbreitung revolutionären Gedankenguts verstärkten sich die Spannungen zwischen der Stadt und dem Umland – im Jahr 1833 wurde Basel in die politischen Einheiten Basel-Stadt und Basel-Landschaft getrennt.

Seit langem gibt es Bestrebungen, die heutigen Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu einem Kanton «Basel» zu vereinen. Unter welchen Voraussetzungen wäre eine solche Wiedervereinigung der beiden Kantone nach der geltenden Bundesverfassung möglich? Inwiefern müsste die Bundesverfassung dafür gegebenenfalls geändert werden?

Eine Bestandesänderung (**1 Punkt**) ist unter den Voraussetzungen von Art. 53 Abs. 2 BV (**1 Punkt**) zulässig:

- Zustimmung der betroffenen Bevölkerung (**1 Punkt**), also der Bevölkerung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land (**0.5 Punkte**).
- Zustimmung der unmittelbar betroffenen Kantone (**1 Punkt**), also der Bevölkerung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land (**0.5 Punkte**).
- Zustimmung von Volk und Ständen (**1 Punkt**).

Da die Bevölkerung und die betroffenen Kantone identisch sind, bräuchte es dafür nur eine Abstimmung (**1 Punkt**). Im Falle einer Bestandesänderung müssten überdies die folgenden Bestimmungen der Bundesverfassung geändert werden:

- Art. 1 BV, da statt Basel-Land und Basel-Stadt nur noch Basel stehen müsste (**1 Punkt**)
- Art. 150 Abs. 2 BV, da der neue Kanton Basel nun wohl zwei Ständeräte wählen dürfte (**1 Punkt**)

- Art. 142 Abs. 4 BV, da der neue Kanton Basel nun wohl eine ganze Standesstimme hätte (**1 Punkt**)

***1 Zusatzpunkt*** *zu Ausführungen zum obligatorischen Referendum mit Doppelmehrerfordernis nach Art. 140 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 142 Abs. 2 BV.*

## Aufgabe 4 — 16 Punkte

*Der Sachverhalt ist frei erfunden!*

Karl ist Arzt und plant, nachdem er im vergangenen Jahr den Facharzttitel für Allgemeine Innere Medizin erworben hat, eine eigene Hausarztpraxis im Kanton Bern zu eröffnen. Gemäss Art. 34 des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 (MedBG) benötigt er hierfür eine kantonale Bewilligung. Eine zentrale Voraussetzung für deren Erteilung ist unter anderem, dass die gesuchstellende Person «vertrauenswürdig ist sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bietet» (Art. 36 Abs. 1 Bst. b MedBG).

Martina hat vor vielen Jahren gemeinsam mit Karl studiert und später mit ihm als Assistenzärztin im Kantonsspital St. Gallen auf derselben Abteilung gearbeitet. Während dieser Zeit unterliefen Karl wiederholt administrative Fehler: Er dokumentierte Leistungen fehlerhaft und vertauschte Patientenakten. Dadurch musste Martina, ohnehin stark belastet, zahlreiche Überstunden leisten, um seine Versäumnisse zu korrigieren. Dies führte nicht nur zu erheblichem Stress für sie, sondern auch zu Spannungen im Team, da Karls Nachlässigkeit regelmässig Missverständnisse und Verzögerungen in der Patientenversorgung verursachte.

Mittlerweile ist Martina beim Gesundheitsamt des Kantons Bern für die Erteilung von Berufsbewilligungen zuständig. Aufgrund ihrer früheren Erfahrungen hält sie Karl für ungeeignet, eine eigene Praxis zu führen. Zudem trägt sie ihm seine damaligen Fehler noch immer nach und will ihm «eins auswischen». Ohne eine Begründung teilt sie Karl daher mit, dass die Voraussetzungen für die Berufsbewilligung nicht erfüllt seien.

**Frage 1:** [10 Punkte]

Karl ist empört über den Entscheid des Gesundheitsamts. Er erblickt darin eine Verletzung seiner Verfahrensgrundrechte. Auf welche Verfahrensgarantie könnte sich Karl im vorliegenden Fall berufen? Wurde diese im vorliegenden Fall verletzt? Begründen Sie.

Im vorliegenden Verfahren entscheidet das Gesundheitsamt des Kantons Bern als staatliche Behörde (**1 Punkt**) über die (individuell-konkrete) Frage, ob Karl eine Berufsbewilligung erhält (**1 Punkt**). Die allgemeinen Verfahrensgarantien gemäss Art. 29 BV sind damit anwendbar (**1 Punkt**). Karl ist als natürliche Person Träger dieser Verfahrensgarantien (**1 Punkt**).

Art. 29 Abs. 1 BV gewährt das Recht auf gleiche und gerechte Behandlung (**1 Punkt**) und verlangt insbesondere, dass am Entscheid nur unbefangene und unparteiliche Personen mitwirken (**1 Punkt**). Da Martina Karl gegenüber voreingenommen ist und ihm «eins auswischen» will, scheint sie aus objektiven Gesichtspunkten befangen zu sein. Sie hätte demnach in den Ausstand treten müssen (**1 Punkt**).

Nach Art. 29 Abs. 2 BV hat Karl Anspruch auf rechtliches Gehör (**1 Punkt**). Teilgehalt des rechtlichen Gehörs ist der Anspruch auf Begründung des Entscheids (**1 Punkt**).

Da das Schreiben des Amts für Baubewilligungen nicht begründet war, wurde das rechtliche Gehör verletzt (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader, § 4, Rz. 46 ff.; Fragenkatalog 2, Fragen 19–21)*

**Frage 2:** [6 Punkte]

Karl will sich gegen den unsachlichen Entscheid des Gesundheitsamtes wehren. Er ist sich jedoch unsicher, ob er dagegen überhaupt gerichtlich vorgehen kann. Hat Karl einen verfassungsmässigen Anspruch auf die Beurteilung durch ein Gericht?

*Hinweis: Das Vorliegen eines Grundrechtsträgers und eines zulässigen Grundrechtsadressaten müssen Sie nicht prüfen.*

Gemäss der in Art. 29*a* BV verankerten Rechtsweggarantie (**1 Punkt**) hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten (**0.5 Punkte**) Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde, sofern dies nicht durch Gesetz ausgeschlossen ist (**0.5 Punkte**).

Eine Rechtsstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt vom Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungsrecht erfasst wird (oder ein Beschwerdeführer dies behauptet) und wenn es um Interessen geht, die vom Recht als «schützenswert» anerkannt sind. Solche Interessen sind z.B. anzunehmen, wenn den betroffenen Privaten Pflichten auferlegt oder Rechte eingeräumt werden, nicht aber wenn es um Interessen der Allgemeinheit geht (**2 Punkte**).

Da die Berufsbewilligung vom MedBG erfasst ist, liegt eine Rechtsstreitigkeit vor (**0.5 Punkt**). Da dem Sachverhalt zudem kein gesetzlicher Ausschluss der gerichtlichen Beurteilung der Rechtsstreitigkeit zu entnehmen ist (**0.5 Punkt**), hat Karl hat Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde (**1 Punkt**).

*(Vgl. Reader, § 4, Rz. 51; Fragenkatalog 2, Fragen 20 und 22 c)*

Universität St.Gallen

# Prüfungsbooklet Assessment

## Rechtswissenschaft I B

### Teil Schmid

**Hinweise:**

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

# Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2025

**Name:** _____ **Vorname:** _____

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

---

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

**2,170**

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

---

Verantwortlich: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid**

---

**Bemerkungen:**

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 16 Seiten (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

| | |
|---|---|
| Aufgabe 1 | 30 Punkte |
| Aufgabe 2 | 10 Punkte |
| Aufgabe 3 | 20 Punkte |
| Aufgabe 4 | 30 Punkte |
| **Total** | **90 Punkte** |

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie **ganze Sätze** und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

## Aufgabe 1: «Für eine Zukunft» (30 Punkte)

Die eidgenössische Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» wurde am 8. Februar 2024 mit 109'988 gültigen Unterschriften eingereicht. Die Initiative sieht die Einführung einer Bundeserbschafts- und -schenkungssteuer vor.

Die vom Initiativkomitee lancierte Volksinitiative hat folgenden Wortlaut:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

**Art. 129*a*** – *Zukunftssteuer*

[1] Der Bund erhebt zum Aufbau und Erhalt einer lebenswerten Zukunft eine Steuer auf dem Nachlass und den Schenkungen von natürlichen Personen.

[2] Der Bund und die Kantone verwenden den Rohertrag der Steuer zur sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise sowie für den dafür notwendigen Umbau der Gesamtwirtschaft.

[3] Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezogen. Der Rohertrag der Steuer fliesst zu zwei Dritteln dem Bund und zu einem Drittel den Kantonen zu. Die Kompetenz der Kantone, eine Erbschafts- und Schenkungssteuer zu erheben, bleibt unberührt.

[4] Der Steuersatz beträgt 50 Prozent. Nicht besteuert wird ein einmaliger Freibetrag von 50 Millionen Franken auf der Summe des Nachlasses und aller Schenkungen. Die Besteuerung erfolgt, sobald der Freibetrag überschritten ist.

[…]

**Art. 197 Ziff. 15**

**15. Übergangsbestimmungen zu Art. 129*a* (Zukunftssteuer)**

[1] Der Bund und die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen über:

1. die Verhinderung von Steuervermeidung, insbesondere in Bezug auf den Wegzug aus der Schweiz, die Pflicht zur Aufzeichnung von Schenkungen und die lückenlose Besteuerung;

2. die Verwendung des Rohertrags zur Unterstützung des sozial gerechten, ökologischen Umbaus der Gesamtwirtschaft, insbesondere in den Bereichen der Arbeit, des Wohnens und der öffentlichen Dienstleistungen.

[…]

**Frage 1)**

Welche Behörde befindet über die Gültigkeit einer zustande gekommenen eidgenössischen Volksinitiative, und in welcher Form ergeht dieser Entscheid (Art des Beschlusses)? (4 Punkte)

*Die Bundesversammlung befindet über die Gültigkeit zu Stande gekommener Volksinitiativen (Art. 173 Abs. 1 Bst. f BV; Art. 98 Abs. 1 ParlG). Der Entscheid ergeht in der Form des einfachen Bundesbeschlusses, der nicht dem Referendum untersteht (Art. 163 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 Abs. 1 ParlG).*

*GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2021, § 23 N. 78, § 18 N. 61*
*Vorlesung 2. Teil (I) Folie 26; (V) Folie 27*

**Frage 2)**

Nennen Sie einen Grund, weshalb sich die zuständige Behörde bei Ungültigerklärungen von Volksinitiativen Zurückhaltung auferlegt. Könnte ein Entscheid betreffend die Gültigkeit beim Bundesgericht angefochten werden? (5 Punkte)

*Die Zurückhaltung der Bundesversammlung bezüglich Ungültigerklärungen von Volksinitiativen ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Gültigkeitsprüfung bereits die erforderliche Anzahl Unterschriften gesammelt worden ist.*

*Akte der Bundesversammlung (und des Bundesrates) können beim Bundesgericht nicht angefochten werden; Ausnahmen bestimmt das Gesetz (Art. 189 Abs. 4 BV). Eine solche gesetzliche Ausnahme liegt hier nicht vor, weshalb die Anfechtung des Entscheids betreffend die Gültigkeit beim Bundesgericht nicht möglich ist.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 78 ff.*
*Vorlesung 2. Teil (VI) Folie 19*

**Frage 3)**

Eidgenössische Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung können entweder in der Form der allgemeinen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfs eingereicht werden.

a) Erläutern Sie, was unter einer allgemeinen Anregung und was unter einem ausgearbeiteten Entwurf zu verstehen ist. In welcher Form wurde die erwähnte Volksinitiative eingereicht? (4 Punkte)

*Mit der Volksinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs wird ein konkreter Text vorgeschlagen, der den bestehenden Verfassungstext verändert. Der Initiativtext kann – abgesehen von offensichtlichen Übersetzungsfehlern und formellen Anpassungen – von der Bundesversammlung nicht angepasst werden (Art. 99 ParlG), d.h. ein ausgearbeiteter Entwurf wird wortwörtlich in die Verfassung aufgenommen, wenn die Volksinitiative in der Abstimmung angenommen wird.*
*Die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung enthält keinen konkreten Textvorschlag, sondern formuliert eine Zielvorstellung für eine künftige Regelung, die durchaus schon einen gewissen Detailierungsgrad aufweisen darf. Eigentliche Textvorschläge, die in der Folge in die Verfassung aufgenommen werden sollten, darf sie jedoch nicht umfassen, da dies eine Vermischung der Initiativform bedeutet. Vielmehr arbeitet die Bundesversammlung eine Verfassungsnorm aus, die der Zielrichtung der allgemeinen Anregung entspricht, und legt diese Volk und Ständen zur Abstimmung vor. Eine allgemeine Anregung ist also so formuliert, dass der Text nicht direkt in die Verfassung übernommen werden soll. Sie stellt vielmehr eine verpflichtende Anregung an das Parlament dar, einen oder mehrere Verfassungsartikel im Sinne der Initiative auszuarbeiten. Sie enthält eine Leitidee und gibt dem Parlament Spielraum bei der Ausarbeitung der Formulierung. (Art. 139 Abs. 2 i.V.m. 4 und 5 BV; Art. 75 Abs. 3 BPR)*

***Subsumtion:** Aus dem Wortlaut ergibt sich, dass der Initiativtext wortwörtlich in die Bundesverfassung übernommen werden kann.*

***Fazit:** Es handelt sich um einen ausgearbeiteten Entwurf.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 88 ff.*
*Vorlesung 2. Teil (I) Folien 23 und 30*

b) Welche der beiden Formen ist in der Praxis beliebter? Nennen Sie zudem je einen Vor- und einen Nachteil der beiden Formen. (5 Punkte)
Hinweis: Nennen Sie nur eigenständige Vor- und Nachteile. Eine Umkehrung (z. B. Vorteil der einen Form = Nachteil der anderen) wird nicht berücksichtigt.

*Der ausgearbeitete Entwurf ist verbreiteter und beliebter als die allgemeine Anregung.*

***Vorteile des ausgearbeiteten Entwurfs:***

- *Das Initiativkomitee kann seine Ideen direkt in den Verfassungstext einbringen und diesen so, wie er lautet, zur Abstimmung bringen.*

***Nachteile des ausgearbeiteten Entwurfs:***

- *Kann dazu führen, dass Entwurf unklar und unausgereift ist*
- *Das Parlament kann die Initiative nicht anpassen, selbst wenn sich Probleme in der praktischen Umsetzung abzeichnen.*

***Vorteile der allgemeinen Anregung:***

- *Erfordert keine Fachkenntnisse, da Ausarbeitung durch das Parlament*
- *Gestaltungsspielraum des Parlaments, um die Initiative in die bestehende Rechtsordnung einzufügen und mögliche rechtliche oder praktische Probleme zu vermeiden*

***Nachteile der allgemeinen Anregung:***

- *Ausarbeitung durch das Parlament und somit nur indirekter Einfluss auf den definitiven Verfassungstext*
- *Evtl. Verzögerung der Umsetzung der Initiative durch das Parlament*

*Anmerkung: Weitere überzeugende Argumente wurden ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 88 ff.*
*Vorlesung 2. Teil (I) Folie 30*

**Frage 4)**

Prüfen Sie, ob die erwähnte Volksinitiative die Einheit der Materie wahrt. (7 Punkte)
Hinweis: Führen Sie die Prüfung vollständig durch, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.

*Mit dem Grundsatz der Einheit der Materie (Art. 139 Abs. 3, Art. 194 Abs. 2 BV; Art. 75 Abs. 1 BPR) soll sichergestellt werden, dass die freie und unverfälschte Stimmabgabe gewährleistet ist (Art. 34 Abs. 2 BV). Die einzelnen Teile der Volksinitiative müssen einen sachlichen Zusammenhang aufweisen (Art. 75 Abs. 2 BPR), damit die Stimmberechtigten ihre Stimme unverfälscht abgeben können. Der sachliche Zusammenhang gilt als gegeben, wenn die Regelungselemente einer Vorlage:*

- *eine einheitliche Thematik betreffen; oder*
- *dasselbe Ziel verfolgen; oder*
- *in einem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinanderstehen.*

***Subsumtion:***

- *Einheitliche Thematik: Die Initiative verlangt neben der «sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise» einen «Umbau der Gesamtwirtschaft». Die beiden Aspekte greifen in verschiedene gesellschafts-, umwelt-, wirtschafts- und steuerrechtliche Bereiche ein, weshalb eine einheitliche Thematik zu verneinen ist. (gegenteilige Argumentation möglich)*
- *Verfolgung desselben Ziels: Die Regelungselemente der Initiative sind alle auf dasselbe übergeordnete Ziel ausgerichtet, nämlich auf den Aufbau und Erhalt einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft.*
- *Zweck-Mittel-Verhältnis: Die Regelungselemente der Vorlage stehen in einem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinander. Die Initiative will mithilfe neuer Steuereinnahmen die Bekämpfung der Klimakrise und den wirtschaftlichen Umbau bewirken. Mit diesen Mitteln soll wiederum das übergeordnete Ziel einer lebenswerten Zukunft erreicht werden.*

***Fazit:** Die Einheit der Materie ist gewahrt.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 71 f.*
*Vorlesung 2. Teil (I) Folien 29 und 31*

**Frage 5)**

Wer entscheidet über den Rückzug einer eidgenössischen Volksinitiative? Welches Quorum ist hierfür erforderlich? Bis zu welchem Zeitpunkt ist ein Rückzug möglich? (5 Punkte)

*Der Entscheid über den Rückzug liegt beim Initiativkomitee, das mit der absoluten Mehrheit der (noch) stimmberechtigten Mitglieder entscheidet (Art. 73 Abs. 1 BPR). Der Rückzug einer Volksinitiative ist zulässig, bis der Bundesrat die Volksabstimmung festsetzt (Art. 73 Abs. 2 BPR).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 95 und 101*

## Aufgabe 2: Parlamentswörterbuch (10 Punkte)

Nennen Sie den gesuchten Begriff und **eine** dazugehörige Rechtsgrundgrundlage in der Bundesverfassung oder einem Bundesgesetz. (Keine Begründung erforderlich)

**Beispiel**
Das _____ schützt die Ratsmitglieder vor verbindlichen Weisungen. Es verbietet jedoch nicht, dass sich die Ratsmitglieder freiwillig an Abreden halten oder dass sie Interessen vertreten. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Instruktionsverbot (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 161 Abs. 1 BV

**Frage 1)**
Als _____ bezeichnet man die Amtsdauer eines Parlaments, nach deren Ablauf eine Gesamterneuerungswahl erfolgt. Auf eidgenössischer Ebene kennt nur der Nationalrat eine solche. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Legislaturperiode (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 149 Abs. 2 BV

**Frage 2)**
Mit einer _____ _____ kann ein Ratsmitglied, eine Fraktion oder eine Kommission den Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorschlagen. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: parlamentarischen Initiative (2 Wörter)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ff. ParlG

**Frage 3)**
Die _____ ist zuständig für die Vorbereitung der Wahl und Amtsenthebung von Richterinnen und Richtern der eidgenössischen Gerichte.

Gesuchter Begriff: Gerichtskommission (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 40*a* ParlG

**Frage 4)**
Die dem _____ _____ unterstellten Erlasse der Bundesversammlung müssen den Stimmberechtigten zwingend zur Abstimmung unterbreitet werden. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: obligatorischen Referendum (2 Wörter)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 140 BV

**Frage 5)**
Die _____ ist die allgemeine Stabsstelle des Bundesrates. Sie berät und unterstützt das Bundesratskollegium und den Bundespräsidenten bzw. die Bundespräsidentin. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Bundeskanzlei (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 179 BV; Art. 32 RVOG

## Aufgabe 3: Bundesstaatsrecht unter der Lupe (20 Punkte)

In den folgenden Texten haben sich mehrere Fehler eingeschlichen. Korrigieren Sie die Fehler direkt im Text, indem Sie ein Wort oder mehrere Wörter ersetzen. Die Nennung von rechtlichen Bestimmungen wird nicht verlangt.

**Text 1) (10 Punkte)**

Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern, die nach jeder Gesamterneuerung des Nationalrates Ständerates, also alle vier Jahre, vom Volk gewählt werden. Der Bundesrat setzt sich von der (Vereinigten) Bundesversammlung grundsätzlich im Verhältnis 3:2:1:1 aus Vertreterinnen und Vertretern der vier wähler- 2:2:2:1 stärksten Parteien zusammen, was als «Ancien Régime» bezeichnet wird. Wenn bei der Zauberformel Wahl eines neuen Mitglieds des Bundesrates eine Unvereinbarkeit vorliegt, ist die Wahl ungültig. Die faktischen Voraussetzungen widerspiegeln nur eine lange Praxis gültig der Bundesversammlung, weshalb die Wahl trotz Missachtung derselben gültig wäre. Nach ihrer Wahl schwören oder geloben die Mitglieder des Bundesrates, die Verfassung und die Konkordanz zu beachten. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Bundesrates werden aus dessen Mitgliedern einzeln und nacheinander für zwei Jahre gewählt. Den Vorsitz im Bundesrat führt die Bundespräsidentin bzw. der Bundespräsident, die auch Ceteris paribus genannt werden. Ein wichtiges Prinzip des Bundesrates ist das Departementalprinzip. Dies bedeutet unter anderem, dass die Mitglieder des Bundesrates Entscheidungen gemeinsam treffen. Weiter wichtig ist das sog. Kollegialprinzip, wonach die sieben Departemente auf die sieben Mitglieder des Bundesrates verteilt werden und jedes Mitglied einem Departement vorsteht.

Gesetze ein Jahr Prima/Primus inter Pares Kollegialprinzip Departementalprinzip

**Text 2) (10 Punkte)**

Das Bundesgericht ist die oberste ~~politische~~ rechtsprechende Behörde des Bundes. Die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts werden von der Vereinigten Bundesversammlung ~~auf Lebenszeit~~ für sechs Jahre gewählt. Die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts müssen ~~ein~~ kein Studium der Rechtswissenschaft abgeschlossen haben. Die Wählbarkeit ist stark an die Parteimitgliedschaft der Richterinnen und Richter geknüpft, woraus sich eine gewisse Politisierung der Wahl ergibt. Deshalb sind auch fast alle Richterinnen und Richter Mitglied einer Partei. Das Präsidium des Bundesgerichts wird durch die Bundesversammlung für ~~drei~~ zwei Jahre gewählt. Der Sitz des Bundesgerichts befindet sich in ~~Bern~~, Lausanne wobei zwei Abteilungen ihren Standort in Luzern haben. Die Hauptaufgabe des Bundesgerichts ist die ~~Verordnungsgebung~~ Rechtsprechung. Das zuständige Richtergremium entscheidet ~~immer~~ häufig schriftlich auf dem Weg der Aktenzirkulation. Die Öffentlichkeit hat jedoch Anspruch auf Information, weshalb unter anderem Urteile von grundsätzlicher Bedeutung veröffentlicht werden. Auch ist es äusserst wichtig, dass die richterliche Unabhängigkeit gewahrt bleibt, die Richterinnen und Richter also weisungsfrei entscheiden können. Das Bundesgericht übt eine ~~umfassende~~ beschränkte Verfassungsgerichtsbarkeit aus; es kann Bestimmungen in ~~Bundesgesetzen~~ kantonalen Gesetzen, die der Bundesverfassung widersprechen, sogar aufheben. Es gibt zwei Arten der Normenkontrolle: die abstrakte und die konkrete. Nur im Fall der ~~konkreten~~ abstrakten Normenkontrolle wird eine Rechtsnorm direkt angefochten.

## Aufgabe 4: Taufe im Genfersee (30 Punkte)

Die evangelische Freikirche von Cologny im Kanton Genf (nachfolgend Freikirche) ersuchte im Mai 2022 beim zuständigen kantonalen Departement (nachfolgend Departement) um eine Veranstaltungsbewilligung zur Durchführung der Tauffeier für eine erwachsene Person durch Eintauchen in den Genfersee an einem öffentlichen Strand. Die Taufe sollte an einem Sonntag zwischen 8.45 und 9.45 Uhr in Anwesenheit enger Freunde und der Familie des Taufempfängers (insgesamt 75 Personen) stattfinden und insbesondere Gebete für den Taufempfänger sowie kurze Gesangseinlagen umfassen. Die Bewilligung wurde der Freikirche verweigert, weil diese nicht zu den religiösen Organisationen gehöre, die vorgängig registriert worden seien.

Gemäss dem kantonalen Genfer Gesetz über den Laizismus können Bewilligungen für religiöse kultische (d.h. rituelle) Veranstaltungen auf öffentlichem Grund erteilt werden, sofern die religiöse Organisation um die erforderliche Registrierung gemäss dem kantonalen Recht ersucht hat. Die Registrierung setzt die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung durch die religiöse Organisation voraus. Die Erklärung beinhaltet die Anerkennung des Vorrangs der Schweizer Rechtsordnung vor allen ihr widersprechenden religiösen Pflichten, insbesondere im Bereich des Familienrechts. Der Aufwand für die Registrierung ist gering: Die betreffenden Organisationen müssen lediglich die Registrierung beantragen und die Verpflichtungserklärung unterzeichnen; anschliessend gelten sie als registriert und sie können darum ersuchen, auf öffentlichem Grund religiöse Veranstaltungen durchzuführen.

Die Freikirche stellt sich hingegen auf den Standpunkt, es widerspreche ihren Überzeugungen, eine Organisation zu sein, die «beim Staat registriert» sei. Deshalb habe sie die Verpflichtungserklärung auch nicht unterzeichnet.

Bei der Freikirche handelt es sich um einen Verein (= juristische Person). Der Zweck wird in den Statuten wie folgt umschrieben: «Die evangelische Freikirche von Cologny verfolgt den Zweck, ihre Mitglieder zusammenzubringen, zu unterstützen und ihre Aktivitäten zu fördern, um die Frohe Botschaft von Christus zu leben und zu bezeugen.»

Die Freikirche sieht in der Verweigerung der Bewilligung für die Tauffeier eine Verletzung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie ihrer Versammlungsfreiheit.

**Frage 1)**
Welche Artikel der Bundesverfassung gewährleisten die Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Versammlungsfreiheit? (1 Punkt)

*Die Glaubens- und Gewissensfreiheit wird in Art. 15 BV, die Versammlungsfreiheit in Art. 22 BV gewährleistet.*

**Frage 2)**
Erläutern Sie zunächst den persönlichen und sachlichen Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie der Versammlungsfreiheit im Allgemeinen. Beantworten Sie anschliessend die Frage, ob die Freikirche Trägerin der Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie der Versammlungsfreiheit ist und ob im vorliegenden Fall die sachlichen Schutzbereiche der beiden Freiheitsreichte betroffen sind. (16 Punkte)

Hinweis: Es ist nur auf den persönlichen und sachlichen Schutzbereich der beiden Freiheitsrechte einzugehen. Eine vollständige Grundrechtsprüfung wird nicht verlangt!

**Persönlicher Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit**
Theorie (Umschreibung des persönlichen Schutzbereichs der Glaubens- und Gewissensfreiheit) (2 Punkte):

*Geschützt von der Glaubens- und Gewissensfreiheit sind alle natürlichen Personen, auch Kinder. Juristische Personen können sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht auf die Religionsfreiheit berufen, es sei denn, sie verfolgen nach ihren Statuten ein religiöses oder kirchliches Ziel.*

Subsumtion (in casu) (2 Punkte):

*Bei der Freikirche handelt es sich gemäss Sachverhalt um eine juristische Person, die gemäss den Statuten ein religiöses/kirchliches Ziel (u.a. Bezeugung der «Frohen Botschaft von Christus») verfolgt.*

Fazit (0.5 Punkte):

*Die Freikirche ist Trägerin der Glaubens- und Gewissensfreiheit.*

**Sachlicher Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit**
Theorie (Umschreibung des sachlichen Schutzbereichs der Glaubens- und Gewissensfreiheit) (3 Punkte):

*Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist das Recht der Einzelnen, in ihrer religiösen Überzeugung sowie deren Ausübung (allein sowie in Gemeinschaft) und Verbreitung nicht durch staatliche Vorschriften eingeschränkt zu werden. Die innere Glaubensfreiheit umfasst das Recht, an*

*anerkannte oder auch nicht anerkannte Religionen zu glauben, das Recht, nicht zu glauben, sowie die Freiheit der Weltanschauung. Die äussere Bekenntnisfreiheit umfasst die Gemeindebildung, das Befolgen von Kleider-, Essens- und Hygienevorschriften, die religiöse Kindererziehung und auch die religiöse Werbung und Weiterverbreitung des Glaubens. Zur Bekenntnisfreiheit zählt auch die Kultusfreiheit, d.h. die Freiheit, in ritueller Form Glaubensbezeugungen zu äussern – sei es individuell (Gebet, Meditation, Fasten usw.) oder kollektiv (Gottesdienst, Taufe usw.).*

Subsumtion (1 Punkt):

*Da die Freikirche eine Taufe durchführen wollte, ist im vorliegenden Fall die äussere Bekenntnisfreiheit betroffen.*

Fazit (0.5 Punkte):

*Der sachliche Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit ist berührt.*

**Persönlicher Schutzbereich der Versammlungsfreiheit**
Theorie (Umschreibung des persönlichen Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit) (1 Punkt):

*Die Versammlungsfreiheit steht allen natürlichen Personen zu. Juristische Personen können sich auf sie berufen, wenn sie eine Versammlung organisieren.*

Subsumtion (in casu) (1 Punkt):

*Bei der Freikirche, welche die Tauffeier organisiert, handelt es sich um eine juristische Person.*

Fazit (0.5 Punkte):

*Die Freikirche ist Trägerin der Versammlungsfreiheit.*

**Sachlicher Schutzbereich der Versammlungsfreiheit**
Theorie (Umschreibung des sachlichen Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit (3 Punkte):

*Die Versammlungsfreiheit gewährleistet das freie Abhalten von Versammlungen. Grundrechtlich geschützt sind Versammlungen, die meinungsbildend sind oder eine Meinungsäusserung bezwecken. Der demokratierelevante Aspekt der Versammlungsfreiheit bezieht sich vorwiegend auf politisch motivierte Versammlungen. Dessen ungeachtet sind auch freundschaftliche, wissenschaftliche, verwandtschaftliche, künstlerische, sportliche oder unterhaltende Zusammenkünfte von Menschen grundrechtlich gewährleistet. Der Inhalt der ausgetauschten und nach*

*aussen hin ausgedrückten Meinungen und Gedanken spielt keinerlei Rolle für den Schutzbereich. Keine Anwendung findet die Versammlungsfreiheit hingegen auf zufällige Ansammlungen von Menschen.*

Subsumtion (in casu) (1 Punkt):

*Die Freikirche möchte sich mit insgesamt 75 Personen an einem öffentlichen Strand am Genfersee versammeln, um eine Taufe durchzuführen.*

Fazit (0.5 Punkte):

*Der sachliche Schutzbereich der Versammlungsfreiheit ist berührt.*

**Frage 3)**
Nehmen Sie an, bei der Verweigerung der Bewilligung für die Tauffeier handle es sich um eine Grundrechtseinschränkung.

a) Erklären Sie zunächst, was man allgemein unter rechtfertigenden Interessen im Rahmen einer Grundrechtseinschränkung versteht. Gehen Sie in der Folge darauf ein, auf welche rechtfertigenden Interessen sich der Kanton Genf im vorliegenden Fall berufen könnte. (6 Punkte)

*Rechtfertigende Interessen im Allgemeinen: Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV). Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichendes öffentliches Interesse gilt etwa der Schutz der Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der Bundesverfassung und der Gesetzgebung. Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.*

*Rechtfertigende Interessen im vorliegenden Fall: Das Erfordernis der staatlichen Registrierung, einschliesslich der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung, bezweckt die Wahrung des religiösen Friedens, die Achtung der schweizerischen Rechtsordnung (öffentliche Ordnung; auch: öffentliche Ruhe) sowie den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Letzteres u.a. deshalb, weil die nicht freiwilligen Zuschauerinnen und Zuschauer eines Kults (z.B. Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Seeufer) zumindest die Gewissheit haben müssen, dass diejenigen, welche ihn ausüben, die hiesige Rechtsordnung bzw. die hiesigen Werte respektieren.*

b) Grundrechtseinschränkungen können von der Intensität her als (eher) leicht oder als (eher) schwer qualifiziert werden. Inwiefern hat diese Qualifikation eine Auswirkung auf die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Massnahme? Handelt es sich im vorliegenden Fall um einen eher leichten oder einen eher schweren Eingriff? (7 Punkte)

Hinweis: Es wird keine Verhältnismässigkeitsprüfung verlangt!

*Theorie Grundrechtsintensität sowie Auswirkung auf die Verhältnismässigkeit: Für die Abgrenzung zwischen schwerwiegenden und leichten Einschränkungen hat die Rechtsprechung bisher kaum gefestigte Kriterien entwickelt. In allgemeiner Weise lässt sich festhalten: Je weiter eine Einschränkung die grundrechtlich vermittelten Ansprüche zurückbindet, desto schwerer wiegt sie. Ob dies zutrifft, ist für jeden Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände gesondert zu untersuchen. Mögliche Indikatoren sind die Persönlichkeitsnähe, die Art und Dauer der Beeinträchtigung und die Auswirkungen auf den Lebensalltag der Betroffenen. Ebenfalls eine Rolle spielen kann die Zahl der von einer Einschränkung betroffenen Personen. Die Intensität wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, auf das subjektive Empfinden des Betroffenen kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht an.*
*Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen durch ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse oder durch einen besonders beachtenswerten Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt werden können, um als verhältnismässig (Verhältnismässigkeit i.e.S. bzw. Zumutbarkeit) und somit als zulässig im Sinne von Art. 36 BV qualifiziert zu werden.*

*Subsumtion: Im Bereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit ist die Beurteilung der Schwere des Eingriffs schwierig, weil religiöse Gefühle und Überzeugungen stets subjektiv begründet sind. Im vorliegenden Fall stellen die Anforderungen an die Registrierung als religiöse Organisation beim Staat – insbesondere die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung und die Verpflichtung zu deren Einhaltung – für sich genommen keinen schwerwiegenden Eingriff in die Religionsfreiheit der Beschwerdeführerin dar. Dies deshalb, weil die Einhaltung der demokratisch festgelegten Regeln des schweizerischen Rechts ohnehin für alle Personen, einschliesslich religiöser Organisationen, verbindlich ist und im Konfliktfall Vorrang vor persönlichen Überzeugungen hat. Diesbezüglich wiederholt die Verpflichtungserklärung bloss eine absolute Selbstverständlichkeit, weshalb von einem eher leichten Eingriff auszugehen ist.*

*Lösungshinweis: Urteil BGer 2C_87/2023 vom 23. Februar 2024*

*Vgl. zum Ganzen BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, §§ 30, 32, 34 N. 54 ff.*
*Vorlesung 2. Teil (II) Folie 9 und (III) Folien 9 ff.*